

1501538-16.2020.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Letícia Pozzi Buassi

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... o já citado auto de exibição e apreensão, o tráfico é consequência lógica das provas colhidas.

Dessa forma, verifica-se que não há apenas indícios de prova, mas sim clareza e harmonia entre elas, no sentido de evidenciar terem os acusados praticado o tráfico ilícito, todavia, em concurso de agentes.

Como bem destacaram as partes, não existe prova, extreme de dúvida, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501538-16.2020.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501538-16.2020.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLÁVIO GABRIEL LIMA DA SILVA e outro

Juíza de Direito: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

FLÁVIO GABRIEL LIMA DA SILVA e BIANCA PARISI CHIQUETO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, combinados na forma do caput do art. 69 do Cód. Penal.

Consta que no dia 28 de novembro de 2020, por volta das 18h13min, na Rua Fausta Colus de Carvalho, 355, nesta cidade e comarca, os réus, agindo em concurso e com identidade de propósitos, traziam com eles, para futura entrega a terceiros, oito porções de "maconha", substância esta entorpecente e determinante de dependência física e psíquica, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ainda, na mesma data, na Rua Itanhém, 362, nesta cidade e comarca, guardava e mantinha em depósito, o réu Flávio, para futura entrega a terceiros, outras duas porções de "maconha", totalizando 276,13g, substância esta entorpecente e determinante de dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Portavam, ainda, os réus, dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, uma faca, um rolo de plástico filme e R\$ 501,00.

Narra, ainda, a inicial, terem se associado, os réus, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Policiais militares, em patrulhamento de rotina, abordaram os réus trafegando na motocicleta "Honda/CG 125 Titan", placa GSN-2842/Itapagipe-MG, localizando-se, com Flávio, um aparelho celular e R\$ 26,00. Na bolsa da ré Bianca, os agentes encontraram um celular, oito porções da droga e R\$ 275,00.

Em seguida, no imóvel de Flávio, localizaram, os policiais, o restante do tóxico, uma balança, uma faca, um rolo de plástico filme e R\$ 200,00.

Oferecida a denúncia foram os acusados notificados e apresentaram defesa prévia.

Recebida a denúncia foram os réus citados e se designou audiência de instrução, na qual se ouviram duas testemunhas arroladas pela acusação e duas apontadas pela defesa.

Após, foram interrogados os réus

Em debate, o representante do Ministério Público, sustentando demonstradas a materialidade dos fatos e a autoria do tráfico de drogas, requereu a condenação dos acusados por este delito, com afastamento do art. 35, caput da lei em tela.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição dos réus alegando, em suma, serem insuficientes as provas a delinear os crimes.

É o relatório.

DECIDO.

Por óbvio, inexistente violação ilícita do domicílio, pois, conforme narrado pelos policiais, sob o crivo do contraditório, o ingresso na residência decorreu, por primeiro, ante o estado de flagrância, constatado pelo encontro das porções dos entorpecentes durante abordagem inicial, e, ao depois, ante autorização dos réus, que, inclusive, acompanharam toda a diligência de busca.

Em se tratando de delito de tráfico de drogas, enquanto o agente possuir substâncias tóxicas, poderá ser preso em flagrante, tratando-se, pois, de crime permanente, propiciando a violabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal.

Assim, em razão do estado de flagrância dos denunciados, excepcionada está a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, devendo ser, portanto, afastada a alegação de irregularidade da diligência policial. Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2. O crime de tráfico de drogas atribuído ao envolvido tem natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. 3. No presente caso, antes do ingresso dos policiais na residência - de acordo com os autos mediante a devida autorização -, o acusado foi abordado em via pública com uma porção de maconha. 4. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2.035.493/AM, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.06.2022).

Além disso, ao contrário do alegado pela defesa, não há nulidade na abordagem policial, tampouco qualquer indicativo de abuso de autoridade, por parte dos agentes. Isso porque, é dever da polícia ostensiva, com base em protocolos pré-existentes e de rígida elaboração, fundados, inclusive, na experiência pessoal, averiguar situações de desrespeito à ordem jurídica e social.

Ademais, in casu, não se observa qualquer indicação de violação de direitos dos réus, que, espontaneamente, indicaram a existência do restante do tóxico, após serem abordados na via, motivando o desfecho da diligência policial.

Afastadas as preliminares, passo à análise do mérito.

A materialidade dos fatos vem comprovada por intermédio do auto de exibição e apreensão (fls. 18/20), que revela o encontro do entorpecente, do dinheiro, dos

celulares, da balança, da faca, do rolo de plástico filme e da motocicleta em tela. Ainda, no pertinente à materialidade, há o laudo de constatação de fls. 24/26 e o laudo de exame químico toxicológico de fls. 120/123, concludentes no sentido de se tratar de Tetrahydrocannabinol - THC, a substância achada.

Os petrechos foram periciados (fls. 126/129), constatando-se resquícios de "maconha" na balança, na faca e no rolo de plástico filme.

A vistoria efetivada nos celulares indicou diálogos relativos à prática da traficância (fls. 286/300).

Na fase policial, assegurou o réu Flávio ter adquirido as porções da droga, em sociedade com o amigo "Vitor", para consumo de ambos, sendo abordado na companhia da corré, com quem mantinha relacionamento amoroso, enquanto estavam em deslocamento para a entrega da substância.

A ré Bianca, na fase administrativa, admitiu o armazenamento, na bolsa, das porções de "maconha", adquiridas por Flávio e um amigo, para consumo, sendo abordados quando em transporte do produto até a residência deste.

Em Juízo, como sói acontecer, assegurou Flávio desconhecer Bianca a existência do tóxico. Contudo, sem apoio no conjunto das provas. A ré confirmou a versão de Flávio.

Contam os policiais terem, em patrulhamento, abordado os réus na condução da motocicleta, ocasião na qual encontraram, nas vestes de Flávio, um aparelho celular e R\$ 26,00. Explicaram ter Bianca, espontaneamente, apresentado oito porções de "maconha", armazenadas na bolsa dela, além de um celular e R\$ 275,00. Acrescentaram que, após indicação de Bianca, houve diligências na residência dos réus, onde encontraram o restante do tóxico e do dinheiro, bem como os petrechos.

Vale lembrar que o fato de policiais que participam de diligências serem testemunhas sobre estas, torna o relato apresentado mais rico em detalhes e, por isso, mais digno de fé.

No caso em tela as declarações apresentaram-se de forma harmônica e coesa com o restante da prova, razão pela qual não podem ser desconsideradas, inexistindo qualquer motivo para que quisessem os agentes incriminar os réus ou forjar os crimes. Neste sentido, vale registrar a seguinte decisão do Eg. Supremo Tribunal Federal: "o valor do depoimento pessoal dos servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.03.2011).

As testemunhas ouvidas em nome da defesa nada acrescentaram ao deslinde da questão. Urge consignar ser grande a quantidade de droga apreendida em comparação à condição financeira dos réus, que não comprovaram relação de emprego, logo, seria imprópria somente a eventual uso, guarda ou transporte, por parte de ambos.

Como não se produziu prova a contrariar o já citado auto de exibição e apreensão, o tráfico é consequência lógica das provas colhidas.

Dessa forma, verifica-se que não há apenas indícios de prova, mas sim clareza e harmonia entre elas, no sentido de evidenciar terem os acusados praticado o tráfico ilícito, todavia, em concurso de agentes.

Como bem destacaram as partes, não existe prova, extreme de dúvida, quanto ao auxílio mútuo entre os réus para a venda de tóxico.

Na situação da abordagem, dividiram os réus as tarefas para que a droga em estudo fosse entregue, sendo abordados em flagrante.

O que importa, no caso, é ter sido o entorpecente localizado com os réus em situação de comercialização, o que acontecia com envolvimento de ambos, para a situação em análise.

Cabia à defesa, nos termos do art. 156 do Cód. de Proc. Penal, a prova certa de não serem os réus pessoas de convívio notório, o que não aconteceu, muito ao contrário,

revelou-se vínculo estreito, pois mantinham relacionamento amoroso.

Por isso, tem-se a destacar estarem as provas testemunhal e técnica em perfeita harmonia, permanecendo isolada a versão dos réus quanto a não serem possuidores do tóxico apreendido, que juntos venderiam.

A análise conjunta das circunstâncias apresentadas leva à conclusão de terem os réus praticado o tráfico de drogas, mas associação não se evidenciou, cabendo a absolvição quanto a este delito.

Neste sentido: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS ASSOCIATIVO ENTRE OS AGENTES. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO EXCEDENTE A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCENTE. MODO FECHADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 3. Não tendo sido apresentado dados concretos que demonstrem efetivamente o animus associativo entre os agentes, uma vez que a condenação está amparada apenas na presunção de que para traficar drogas no Complexo do Chapadão, localidade sob o comando da facção criminosa denominada "Comando Vermelho", o paciente necessariamente deveria integrar a referida organização e teria uma função pré-determinada, a absolvição pelo delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 é medida que se impõe." (STJ, HC 415.974/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 11/10/2017). Além disso, a quantidade de entorpecente apreendida e a forma de embalagem, somadas às circunstâncias acima analisadas, nos moldes do art. 239 do Cód. de Proc. Penal, levam à dedução de que seria por ambos os réus posta em comércio, até porque, não contam com situação financeira que os permita manter tal quantidade de droga para outro fim.

É possível que façam os réus uso do tóxico, mas a venda é certa, até para garantia do uso.

Além disso, a condição de usuário não afasta a de traficante.

Convencida da responsabilidade penal dos réus, passo a individualizar as penas.

- FLÁVIO GABRIEL LIMA DA SILVA:

- art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por não ostentar maus antecedentes.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

- BIANCA PARISI CHIQUETO:

- art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por não ostentar maus antecedentes.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão, para ambos os réus, é o fechado (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.464/07).

Deixo de aplicar o § 4º do art. 33 da lei em tela, ante a quantidade de entorpecentes e o concurso de agentes, fatos a apontar maior periculosidade dos réus, indicando dedicarem-se à atividades criminosas.

Neste sentido, o RHC nº 116.926, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/9/13, no qual se decidiu que: "a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/2/2010" (g.n.).

O valor unitário do dia-multa é o mínimo legal, considerada a situação econômica

dos acusados (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e condeno FLÁVIO GABRIEL LIMA DA SILVA, R.G. n.º 45.706.872 e BIANCA PARISI CHIQUETO, R.G. n.º 37.094.138, cada um, a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, por terem infringido o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c. c. o art. 29, caput, do Cód. Penal, combinados na forma do caput do art. 69 do Cód. Penal.

Absolvo FLÁVIO GABRIEL LIMA DA SILVA, R.G. n.º 45.706.872 e BIANCA PARISI CHIQUETO, R.G. n.º 37.094.138, da prática do delito previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Cód. de Proc. Penal.

Porque aguardaram os réus a instrução do feito em liberdade, faculto eventual apelação nessa mesma condição, devendo-se observar as medidas cautelares determinadas às fls. 81/82.

A pena pecuniária será atualizada a partir da data do fato, uma vez que a correção monetária não apresenta nenhum plus, mas sim tentativa de reposição do poder aquisitivo da moeda.

Força concluir ainda, que a multa não corrigida perde o caráter aflitivo, tornando inútil a imposição, inatendidas as finalidades da sanção penal de punição, dissuasão e reeducação dos delinquentes.

Observados o art. 63 da Lei nº 11.343/06 e o art. 91, inc. II, "b", do Cód. Penal, DETERMINO O PERDIMENTO da motocicleta e dos petrechos (fls. 18/20), porque utilizados como instrumentos do delito, bem como dinheiro e dos celulares (fls. 16/17), pois obtidos em razão do comércio ilícito de drogas, conforme prova colhida. Para tanto, oficie-se ao FUNAD.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, oficie-se à Autoridade Policial para que se proceda a destruição das amostras de entorpecente guardadas para contraprova.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

P.R.I.C..

São José do Rio Preto, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA